

1500678-98.2019.8.26.0187

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/01/2022

... procedência em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia, e a improcedência, em relação a associação para o tráfico (art. 35), em razão de não demonstrada a reiteração na prática delitiva. Alegou que imperiosa a fixação de regime fechado e incabível a substituição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500678-98.2019.8.26.0187 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500678-98.2019.8.26.0187

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2332440/2019 - DEL.POL.TAGUAI, 8556006 - DEL.POL.TAGUAI, 418/19/112 - DEL.POL.TAGUAI, 2332440 - DEL.POL.TAGUAI, 418/19/112 - DEL.POL.TAGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO VITOR DE MELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ALEXSANDRO VITOR DE MELO e DAVID SOLDEIRA FELIX, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

A denúncia (fls. 86-89) narra, em síntese, que em data e local desconhecidos, mas durante período que perdurou até às 10h45min de 14/11/2019, os acusados Alexsandro e David, "associaram-se para o fim de prática, ainda que não reiteradamente, o crime de tráfico de drogas". Ainda, às 10h45min de 14/11/2019, os acusados Alexsandro e David traziam consigo 12 porções embaladas de maconha, totalizando 16,38g, para fins de venda e comercialização, sem autorização e em desacordo com as

determinações legais.

As prisões em flagrantes foram homologadas com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 42-50).

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 118; 144).

A denúncia foi recebida na data de 01 de março de 2021, não sendo concedida absolvição sumária e sendo determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 145-147).

Foi decretada a revelia do acusado Alexsandro (fl. 202), a qual posteriormente foi reconsiderada em audiência (fl. 226 – mídia anexa), em razão da informação de que o acusado estava preso. Nesta mesma oportunidade, foi decretada a revelia do acusado David.

Foi nomeado novo advogado à defesa de David, em razão da colidência de defesas (fl. 259).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado David, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou pela parcial procedência da ação, argumentando que devida a procedência em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia, e a improcedência, em relação a associação para o tráfico (art. 35), em razão de não demonstrada a reiteração na prática delitiva. Alegou que imperiosa a fixação de regime fechado e incabível a substituição de pena, na forma do art. 44, do CP.

A Defesa de Alexsandro, apresentou alegações finais (fls. 261-266), pleiteou a sua absolvição em face da insuficiência probatória que cerca o lastro probatório contido nos autos, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Alegou, subsidiariamente, que devida a desclassificação, sustentando que o acusado estava somente comprando drogas e com ele nada teria sido encontrado.

A defesa de David ofertou alegações finais (fls. 269-278) sustentando, em síntese, que devida a absolvição, uma vez que inexistem provas suficientes para comprar que o acusado estivesse praticando o delito que lhe é imputado. Subsidiariamente, postula pela desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. Ainda tem tese subsidiária, postula pelo reconhecimento da menoridade relativa, fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena na forma do art. 44, do CP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, passo à análise do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência de fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT,

2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ

Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

"DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente." (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

"Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a

condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaqueei).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição (fl. 09), fotos (fls. 10-12), auto constatação preliminar (fl. 13), laudo pericial (fls. 79-82) e prova oral produzida em juízo.

4. Passo às considerações a respeito da autoria.

A testemunha Rodrigo de Queiroz narrou, em síntese, que por volta das 09h00 dirigiu-se ao departamento da polícia militar para informar a respeito de venda de drogas, tendo se dirigido ao local dos fatos, juntamente com o policial Gilson, quando Alexsandro e David saíram de 'uma biquinha de água em direção à pista'. Em seguida, estacionaram o carro e ficaram observando, tendo notado que os acusados dispensaram algo no canteiro central (da rodovia). Na sequência, o policial Gilson fez a abordagem, não encontrando nada em posse dos acusados, mas tendo observado que o objeto dispensado era a porção de droga apreendidas nos autos. Narrou que os acusados tentaram empreender fuga, mas capturados. Esclareceu que foi Alexsandro quem dispensou as drogas. Afirmou que o local é conhecido por venda e uso de drogas. Disse que os acusados são conhecidos na cidade por serem vendedores de drogas, já tendo, inclusive, visto o acusado Alexsandro no local.

A testemunha Gilson Aparecido Pereira (policial militar) narrou, em síntese que uma pessoa compareceu a base da polícia militar, noticiando venda de drogas. Em seguida, saiu, na companhia dessa pessoa, para diligências nos locais indicados como pontos de venda de drogas. Ao chegar ao cruzamento da Rodovia SP 249, cruzamento com a rua Fernando Gobbo, notou dois indivíduos atravessarem a rua e afirmou que quando as pessoas observaram a viatura pararam no canteiro que no meio da via, tendo Alexsandro dispensado algo. Em seguida, em razão da atitude, deu voz de apreensão as pessoas, tendo feito revista pessoal, não tendo encontrado nada, mas em seguida foi ao local em que notou que algo havia sido dispensando e viu duas porções de maconha. Na sequência, os indivíduos empreenderam fuga, mas foram capturados. Disse que nenhum dos dois assumiu a propriedade da droga, cada um implicando ao outro a posse da droga. Especificou, que um deles teria dito que usariam a droga juntos e o outro dito que fariam o fracionamento da droga em conjunto, não recordando qual versão teria sido passada por quem. Afirmou que Alexsandro é conhecido dos meios policiais por suspeitas de tráfico e que não conhecia David anteriormente. Disse que não foram encontrados apetrechos para o uso de drogas e que a substância estava fracionada em várias porções.

Em Juízo, o acusado Alexsandro disse que estava em casa quando David lhe chamou dizendo que iria ao banco pegar dinheiro e comprar maconha, em seguida, David voltou a sua casa lhe convidando para fumar maconha. Na sequência, David pediu para que lhe ajudasse a embalar a droga, tendo o depoente auxiliado. Depois, estavam voltando para a casa do depoente, momento em que aconteceu a abordagem. Narrou a abordagem em conformidade com as narrativas anteriores - isto é, tendo ficado sentados após avistarem a viatura, dispensado a droga e sido abordados. Afirmou que ajudou que David embalasse a droga, mas não sabia que era para venda e em momento algum desconfiou disso. Relatou ser amigo de David, mas não o conhecia a muito tempo. Afirmou ter usado maconha em companhia de David.

Diante deste contexto, entendo que autoria e materialidade estão comprovadas. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que as testemunhas narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de

que elas tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que as testemunhas asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Ainda neste contexto, em relação ao depoimento do policial militar Gilson (responsável pelas prisões em flagrante), a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Ademais, o próprio acusado Alexsandro, embora tenha negado a prática de traficância, confirmou que estava em posse das drogas, tendo as dispensado quando notou a presença da viatura policial.

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram em parte a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

Note-se que pela versão apresentada em juízo é possível concluir que os acusados estavam cruzando a SP 249 quando notaram a aproximação da viatura policial e sentaram-se no canteiro do meio da via, tendo Alexsandro dispensado, antes da abordagem a porção de drogas objeto dos autos. Em sequência foi realizada revista pessoal nos acusados, na qual nada foi encontrada, e localizada, no solo, a porção de maconha que lançada antes da aproximação da polícia. Em seguida, os acusados empreenderam fuga, mas foram capturados.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autorias e materialidades da conduta descrita na exordial.

5. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

5.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (grifo nosso).

Entretanto, embora se trate de tipo plurinuclear alternativo, faz-se necessária a comprovação do dolo na prática da traficância - isto é, a demonstração de que o

agir nuclear do tipo se orienta pela finalidade do cometido do ato de tráfico de drogas.

Não sem razão.

Tratando-se delito que expõe diversas ações como típicas, faz-se imprescindível que o cometido da conduta esteja orientado pela finalidade do delito – eis, aqui, um exemplo sintomático da adoção da teoria finalística –, sob pena de tipicidade do art. 33, da Lei 11.343/06, dissolva-se para demais espécies penais, violando, assim, a legalidade penal. Por exemplo, a conduta de 'trazer consigo' ou 'transportar' são espécies nucleares do tipo do art. 33, da Lei de Drogas, porém são também hipóteses que, por vezes, inerentes ao uso de drogas (art. 28). Daí a imperiosa necessidade de demonstrar que a comprovação da conduta típica está orientada pela finalidade de traficância.

No caso em análise, entendo que, a despeito da comprovação do fato de que os acusados traziam consigo a droga, há dúvida a respeito da efetiva traficância. É que, embora esteja comprovado que os acusados – especificamente, Alexsandro, pouco antes da abordagem, conforme relatos – estavam inequivocamente em posse das drogas, há, pelo menos, 'razoável dúvida', a respeito de qual era sua intenção com ao transportá-las.

Isto porque, a despeito da posse, não restou caracterizado, de maneira a satisfazer o standard probatório do processo penal, que os acusados tivessem a intenção de distribuição ou comercialização a terceiros as substâncias apreendidas com eles. No ponto, observe-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos é bastante modesta (16,38g de maconha), não foi observado ou constatado nenhum ato de traficância e os acusados, sempre que ouvidos, disseram que pretendiam utilizar a droga. Não se olvida que existem alguns indícios que podem, eventualmente, indicar a traficância (porções individualizadas de drogas, ausência de apetrechos para o uso, contradições nos depoimentos dos acusados). No entanto, tais circunstâncias não demonstram de maneira segura que os acusados pretendiam traficar, não sobrepunhando, pois, o ônus probatório inerente ao processo penal, na medida em que se permite inferir a existência de cenários que implicariam em um lapso lógico entre as premissas (acusados estavam em posse das drogas) e conclusões (acusados estavam traficando).

Em outras palavras: há, não se olvide, elementos que autorizam a suposição/suspeita de que os acusados estavam cometendo o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, não existem elementos probatórios suficientes para assegurar que os acusados tenham realmente cometido tal crime, em especial porque são cogitáveis hipóteses que preencham as circunstâncias iniciais (posse das drogas) e não conduzam, necessariamente, a conclusão de que os acusados estavam traficando. Ao fim e ao cabo, são possíveis pressuposições circunstâncias, que fundamentem um juízo de possibilidade. Porém, diante do contexto probatório, não é viável uma conclusão segura, que conduza a satisfação do standard probatório exigido para uma condenação penal.

Nesse sentido, entendo que há razoável dúvida a respeito da prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

5.1.1. No entanto, considerando as alegações do acusado e a comprovação da autoria e materialidade, entendo que caracterizada a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/03.

No ponto, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido que a tipificação estabelecida no art. 28, da Lei 11.343/06, padece de inconstitucionalidade, na medida em que, em decorrência do princípio da lesividade/ofensividade penal – o qual decorre diretamente do direito de liberdade, previsto no art. 5º, caput, e X, da CF –, é incompatível com a ordem constitucional a criminalização de condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros.

É que, conforme bem expos John Stuart Mill, em seu célebre ensaio Sobre a Liberdade: “só o dano para os interesses de outros – ou a probabilidade elevada de haver dano – pode justificar a interferência da sociedade” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almedina/Saraiva, 2011, p. 86).

“Nenhuma pessoa devia ser punida simplesmente por estar bêbada; mas um soldado ou

um polícia devia ser punido por estar bêbado em serviço. Resumindo: sempre que há um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei.

Mas em relação ao dano meramente contingente ou, como pode ser chamado, estrutural, que uma pessoa causa à sociedade através de conduta que nem viola qualquer dever específico para com o público, nem dá azo a danos perceptíveis para qualquer indivíduo definido senão ela mesma, a sociedade pode dar-se ao luxo de suportar essa inconveniência, tendo em vista o bem maior da liberdade humana. Se fosse para punir adultos por não tomarem bem conta de si, preferia que fosse para seu próprio bem, e não com o falso pretexto de os impedir de diminuir a sua capacidade de prestar à sociedade benefícios que esta não finge ter o direito de exigir. Mas não posso aceitar discutir o assunto como se a sociedade não tivesse quaisquer outros meios de elevar os seus membros mais fracos ao padrão normal da conduta racional, a não ser esperar que fizessem algo irracional, e depois puni-los, legal ou moralmente, por isso.” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 77).

A posição não é distinta na doutrina jurídica.

Conforme exposto, pelo Prof. Salo de Carvalho, em sua tese de mestrado, A Política Criminal de Drogas no Brasil:

“O princípio da lesividade ou da ofensividade complementa, de forma organizativa, o princípio da intervenção mínima. O princípio dispõe que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que a ação infrinja bem jurídico determinado, produzindo-lhe dano - resultado material. Quatro funções específicas são delineadas pelo princípio da lesividade, segundo Nilo Batista: a. proibição de incriminações de atitudes internas; b. proibição de criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor; c. proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais; e, d. proibição de criminalização de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico específico. [...].

Sobre a incriminação de atos que não excedam o próprio autor, o princípio se refere à proibição de incriminação de autolesões, crimes impossíveis e atos preparatórios. Relativo ao caso das drogas, toma-se questão fundamental a análise do bem jurídico tutelado e a potencialidade da lesão, principalmente nas condutas usuais.”

(CARVALHO, Salo. A Política de Drogas no Brasil, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC, 1996, p. 108-109 - negrito original, grifos próprios).

Também nesse sentido:

“A despeito da importância dada por alguns autores funcionalistas ao conceito de bem jurídico para a afirmação da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a existência e tutela penal do bem jurídico somente tem importância se esse conceito for considerado em conjunto com a ofensividade mínima que se exige para a caracterização da tipicidade material do delito (ZAFFARONI, et al., 2010, p. 212). [...].

Em face do princípio da lesividade ao bem jurídico, para E. Raúl Zaffaroni, são ilegítimas incriminações penais que imponham uma determinada moral ou que tenham conteúdo simbólico (ZAFFARONI, et al., 2010, p. 221). Postula também a ilegitimidade do uso da legislação penal a situações em que, embora absolutamente ineficaz para os resultados a que se destina, talvez até mesmo agravando-os, o legislador utiliza-a para tranquilizar a opinião pública e de este modo, proveer al clientelismo político (ZAFFARONI, et al., 2002, p. 489).

Nesse sentido, é de reconhecer-se como função da ofensividade a limitação ao Poder Legislativo, uma vez que devem ser consideradas inconstitucionais as intervenções penais que criminalizam condutas que não ofendem ou sequer geram perigo concreto de lesão a bens jurídicos.

Esses limites impostos ao legislador quando da incriminação de condutas foram sistematizados por Nilo Batista, ao afirmar que o princípio da lesividade tem as seguintes funções: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a

incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais; e d) proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, tendo-se por desviada a conduta fortemente desaprovada pela coletividade (BATISTA, 1999, p. 92 e ss).

De fato, não se pode deixar de constatar a inconstitucionalidade de intervenções estatais desse jaez, na medida em que a Constituição consagra o direito à liberdade de opinião e de expressão (art. 5º, IV, VI), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X) e o pluralismo político e social (art. 3º, IV).

Assim, manifesta-se a inconstitucionalidade de intervenções estatais com tais conteúdos na medida em que reduzem direitos fundamentais, sem que qualquer finalidade social possa ser antevista nessas intervenções. As intervenções estatais são inconstitucionais se não tiverem por finalidade assegurar os objetivos da República Federativa do Brasil expressos no art. 3º da CR/88. Pelo contrário, o que se vislumbra em incriminações sem ofensa a bens jurídicos é que elas não apenas distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade livre (art. 3º, I, CR/88) como ainda ampliam a marginalização, que é objetivo estatal eliminar (art. 3º, III, CR/88). Não se pode perder de vista que: O mais importante compromisso vinculador da atuação do Estado brasileiro decorrente da natureza de nossa Constituição (pacto social) é o reconhecimento da existência de um núcleo inviolável de direitos, constituído pelos direitos fundamentais, cuja tutela é prioridade máxima do Estado e que não podem ser suprimidos nem mesmo a pretexto de atender à vontade da ampla maioria ou ao consenso existente na sociedade. (BRODT, 2005, p. 33).” (ÂREDE, Sirlene Nunes. O Princípio da Ofensividade e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in: Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 55, p. 36-45, out./dez. 2011, p. 37-38).

Além disso, não se pode olvidar que tramita, perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE 635659), com questão de repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade da previsão normativa do art. 28, da Lei 11.343/06.

É certo que o caso ainda está pendente de julgamento definitivo. Porém, é igualmente inequívoco que os Ministros Gilmar Mendes (relator), Luís Roberto Barroso e Edson Fachin já proferiram votos no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade.

Neste contexto, transcreve-se trecho paradigmático do voto do Ministro Relator: “Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação.

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais.

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita.

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. São ilustrativos, nesse sentido, os exemplos citados por DANIEL PRADO (Boletim, IBCRIM, outubro/2012, p. 8-9), verbis: [...].

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade

e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde.

Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. Cabe registrar que, com esse mesmo entendimento, a Corte Constitucional alemã negou, em 1994, no julgamento do caso Cannabis, a existência de semelhante direito (Recht zum Rausch), afirmando, com isso, a viabilidade da criminalização do tráfico de cannabis sativa (BverfGE 90,145, 9.3.1994).

Também explicitou que o art. 2, I, da Lei Fundamental alemã, assegura o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas que o uso de drogas, em especial graças à forte repercussão social que tem, não pode estar nele incluído. Não haveria, assim, um direito a “ficar intoxicado” (“Recht auf Rausch”) assegurado pela Lei Fundamental.

O Tribunal considerou, todavia, que casos envolvendo posse, compra ou importação de pequenas quantidades de maconha para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de culpa e da proporção do dano causado.

De forma resumida, o §31 da lei alemã sobre narcóticos (“Betäubungsmittelgesetz”) estabelece que a posse de pequenas quantias de drogas pode não ser criminalizada, exceto em caso de interesse público, e autoriza os promotores a encerrar o caso sem consultar o Judiciário.

Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza penal.

Na Espanha, por exemplo, entre as sanções administrativas previstas na legislação, há multas de até 30 mil euros e/ou a suspensão da carteira de motorista. São medidas, como se percebe, bem mais eficazes na contenção do consumo do que a simples aplicação de medidas penais sem resultados práticos demonstráveis.

Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas.

Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade.

Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social.

A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal.

Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal.

Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” (Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RE 635659 – grifos próprios).

Não distinto foi o posicionamento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

“VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO

Do ponto de vista jurídico, há pelo menos três fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição:

1. Violação ao direito de privacidade

A intimidade e a vida privada, que compõem o conteúdo do direito de privacidade, são direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune a interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. Sobretudo, quando não afetar a esfera jurídica de um terceiro.

Ex. É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área.

2. Violação à autonomia individual

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia, absoluta, ela pode ser restringida pela lei. Porém, a liberdade possui um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.

Exs mais óbvios: o Estado e a sociedade não podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou que profissão você vai seguir.

As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher os seus prazeres legítimos. Há quem faça alpinismo, voe de ultraleve, participe de corridas de automóvel, ande de motocicleta ou faça mergulho submarino. Todas essas são atividades que envolvem riscos. Nem por isso são proibidas. O Estado pode, porém, limitar a liberdade individual para proteger direitos de terceiros ou determinados valores sociais.

Pois bem: o indivíduo que fuma um cigarro de maconha na sua casa ou em outro ambiente privado não viola direitos de terceiros. Tampouco fere qualquer valor social. Nem mesmo a saúde pública, salvo em um sentido muito vago e remoto. Se este fosse um fundamento para proibição, o consumo de álcool deveria ser banido. E, por boas razões, não se cogita disso.

Note-se bem: o Estado tem todo o direito de combater o uso, fazer campanhas contra, educar e advertir a população. Mas punir com o direito penal é uma forma de autoritarismo e paternalismo que impede o indivíduo de fazer suas escolhas existenciais. Para poupar a pessoa do risco, o Estado vive a vida dela. Não parece uma boa ideia.

3. Violação ao princípio da proporcionalidade

O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, na sua dimensão instrumental, funciona como um limites às restrições dos direitos fundamentais. Para que a restrição a um direito seja legítima, ela precisa ser proporcional. Em matéria penal, tal ideia se expressa em alguns conceitos específicos, que incluem a lesividade da conduta incriminada, a vedação do excesso e a proibição da proteção deficiente.

O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio. De modo que se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização. O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota,

provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em segundo lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas que poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. O efeito, portanto, é inverso. Portanto, não havendo lesão a bem jurídico alheio, a criminalização do consumo de maconha não se afigura legítima.

O teste da proporcionalidade inclui, também, a verificação da adequação, necessidade e proveito da medida restritiva. A criminalização, no entanto, não parece adequada ao fim visado, que seria a proteção da saúde pública. Não apenas porque os números revelam que a medida não tem sido eficaz – o consumo de drogas ilícitas, inclusive da maconha, tem aumentado significativamente –, como pelas razões expostas acima: a saúde pública não só não é protegida como é de certa forma afetada pela criminalização.

A questão da necessidade poderia ser disputada. Há países que optam por criminalizar a maconha. Mas em número decrescente. Na América Latina, como visto, somente Brasil, Suriname e Guianas tratam o porte de drogas para uso pessoal como crime. Existem alternativas que vão desde a previsão de sanções administrativas até o combate via contrapropaganda e cláusulas de advertência.

Mas é sobretudo no terceiro subprincípio – o da proporcionalidade em sentido estrito –, quando se vai aferir o custo benefício da criminalização que a desproporcionalidade se evidencia de maneira mais contundente. O custo tem sido imenso – em recursos drenados para a repressão, para o sistema penitenciário, nas vidas de jovens que são destruídas no cárcere, no poder do tráfico sobre as comunidades carentes – e os resultados têm sido pífios: aumento constante do consumo.

Em suma: por ausência de lesividade a bem jurídico alheio, por inadequação, discutível necessidade e, sobretudo, pelo custo imenso em troca de benefícios irrelevantes, a criminalização não é a forma mais razoável e proporcional de se lidar com o problema.

Pelos mesmos fundamentos, declaro a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 1º do artigo 28 da Lei n 11.343/2006, o qual prevê que se submete às mesmas penas do caput, “quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”. Aqui, à falta de um critério específico para delimitar o que seja pequena quantidade para consumo pessoal, utilizo o parâmetro adotado no Uruguai, que é de 6 (seis) plantas fêmeas.” (Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no RE 635659 – negritos originais, grifos próprios).

Entretanto, é fato que não existem precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. Ao contrário, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a constitucionalidade da norma supracitada. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas e reconheceu sua inconstitucionalidade – Recurso Ministerial – De rigor a inversão do decisum – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1500247-53.2021.8.26.0556; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

“Apelação criminal – Porte de drogas para uso próprio – Juizado Especial de origem que declinou sua competência para a Justiça Comum de Primeiro Grau, diante da impossibilidade de localização do réu – Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade, seja por inconstitucionalidade do art. 28, da Lei de Drogas, ou por aplicação do dito 'princípio da insignificância'. Ausência de recurso Ministerial. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 14g (catorze gramas) –

Acusado que, na fase extrajudicial, assumiu a posse do entorpecente, não tendo comparecido em Juízo, onde foi decretada a sua revelia – Depoimento seguro do Policial Militar em Juízo confirmando a localização de entorpecentes na residência do réu – De rigor a manutenção da condenação pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. 'Princípio da insignificância' – Impossibilidade de reconhecimento – Trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Inconstitucionalidade não reconhecida – conduta despenalizada, mas que permanece criminalizada pela Lei nº 11.343/06. Dosimetria – Patamar das penas de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa que não comporta reparos, especialmente em face da reincidência advinda de tráfico privilegiado. Recurso Defensivo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500668-61.2018.8.26.0099; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).

"Posse de maconha – Insignificância do ato – Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Inexistência – Condenação mantida; Furto qualificado – Escalada – Ausência de laudo pericial – Não caracterização – Inteligência do art. 158, do Código de Processo Penal; Furto – Multirreincidência – Confissão – Preponderância da agravante sobre a atenuante – Impossibilidade – Compensação integral – Não cabimento – Recurso provido em parte para redução da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1501253-43.2020.8.26.0617; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021).

Portanto, considerando os reiterados julgados do e. TJ-SP reconhecendo a constitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06, bem como considerando que ainda está pendente de julgamento definitivo, – a despeito de votos já proferidos – o RE 635659, que tramita no Supremo Tribunal Federal, ressalvo meu entendimento pessoal e deixo de reconhecer a inconstitucionalidade da previsão normativa em comento.

5.2. A norma penal prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, expõe como típica a conduta de "Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei".

Conquanto o texto normativo determine como típica a conduta, independente de reiteração, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a 'estabilidade e permanência' são imprescindíveis. Por todos, veja-se:

"1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes." (RHC 108.003/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No ponto, a jurisprudência – de maneira acertada – destaca, ainda, que os requisitos de 'estabilidade e permanência', exigidos para a configuração do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, são distintos do elemento de reiteração – este sim dispensado.

"1.5. A estabilidade e permanência, que são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico." (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, o que se verifica é que para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, faz-se necessário demonstrar que a associação para o tráfico preenche os requisitos de 'estabilidade e permanência' – requisitos que, note-se, também são exigidos para a configuração do crime do art. 288, do CP (associação criminosa) –, prescindindo, no entanto, da comprovação de reiteração. Em outras palavras: a conduta do art. 35, da Lei 11.343/06, é típica, ainda que

cometida uma única vez (ausência de reiteração), desde que demonstrada a 'estabilidade e permanência'.

No ponto, destaque-se que a exigência de estabilidade e permanência não ofende ao princípio da legalidade. Ao contrário, somente afirma uma diferença normativa e ontológica entre os art. 29, do CP (concurso de pessoas) e o tipo do art. 35, da Lei 11.343/06 (ou, para tais fins, também do art. 288, do CP). Afinal, há uma distinção essencial – reconhecida pelo legislador, sendo, portanto, também normativa – entre o cometimento de um delito juntamente com outro agente (art. 29, do CP – concurso de pessoas) e a associação para o cometimento de delitos (art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 288, do CP). Esta distinção é, justamente, a 'estabilidade e permanência'.

In casu, não restou demonstrado que os acusados tenham se associado, com estabilidade e permanência, para praticar as condutas previstas no art. 35, da Lei de Drogas. Ao longo da instrução não se apresentou qualquer prova nesse sentido. Não por outra razão, o i. representante do Parquet não postulou pela condenação no ponto. E razão, efetivamente, lhe assiste.

Ademais, conforme acima exposto, não ficou comprovada, para além de dúvida razoável, a traficância, de forma que, também por este motivo, a conduta de associação para o tráfico, imputada aos acusados, se torna atípica.

Pelo exposto, seja em razão da ausência de comprovação de estabilidade e permanência, sejam pela não efetiva comprovação da traficância, é imperioso o reconhecimento da atipicidade em relação a imputação do art. 35, da Lei 11.343/06.

6. Comprovada a prática do tipo do art. 28, da Lei 11.343/06, observo que a respeito dos demais elementos do injusto, os acusados são imputáveis, têm